

1500551-71.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... dos réus (cumprimento de mandado de prisão por tráfico em desfavor da acusada Carla), a forma de acondicionamento da droga (distribuídas em porções prontas para o comércio); apreensão de sacos plásticos "zip lock", balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e dinheiro; a confissão informal dos réus aos policiais militares; e a confissão apresentada pelo réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500551-71.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500551-71.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097842/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 24195992 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2097842 - 02º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLA FERNANDA FANI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500551-71.2022.8.26.0603 (Controle nº 815/2022).

VISTOS.

RAPHAEL NAYA SOUTO e CARLA FERNANDA FANI, qualificados nos autos, foram presos em

flagrante delito, denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 16h40, na Rua Osorio Hilario Pontes, nº 743, Novo Jardim

Toselar, nesta cidade e comarca de Birigui, RAPHAEL NAYA SOUTO e CARLA FERNANDA FANI, tinham em depósito 103 (cento e três) porções de cocaína, pesando 65,71 gramas (massa bruta), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fl. 18 e laudo toxicológico definitivo de fls. 264/266.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas acima, RAPHAEL NAYA SOUTO e CARLA FERNANDA FANI possuíam nas dependências de sua residência, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, número KJR95621, de uso permitido, acompanhada de 16 (dezesesseis) munições íntegras, marca CBC, calibre 380, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de exame pericial de fls. 268/272.

Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à acusada Carla e convertida a prisão em flagrante do réu Raphael em prisão preventiva (fls. 90/93). Recebida a denúncia em 05 de maio de 2022 (fls. 178/179), os acusados foram regularmente citados (fls. 219 e 220) e apresentaram defesas escritas às fls. 210 e 215/216.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, o interrogatório dos acusados (fls. 277/278). Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 313/318).

Por outro lado, a defesa da acusada Carla requereu a absolvição, alegando ausência provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu seja a prisão corporal substituída por prisão domiciliar (fls. 321/323).

Por sua vez, a defesa do réu Raphael alegou, em preliminar, nulidade em razão de a busca ter sido realizada na residência sem mandado. No mérito, requereu a absolvição do acusado, alegando inexistência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado; a aplicação das penas no mínimo legal; a fixação do regime mais brando; a detração penal; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo (fls. 352/370).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/03).

De início, a alegação da defesa do réu Raphael quanto à busca domiciliar na casa, sem mandado judicial, fica rejeitada.

Pelo que se relatou, durante patrulhamento pelo Bairro Toselar, os policiais Alekssander e Rafael receberam a informação de que uma mulher foragida da justiça, de prenome Carla, estaria residindo na rua Santos Puerta Garcia, nº 834, e usava um automóvel Toyota/Corolla, de cor preta.

Os policiais realizaram o acompanhamento e a abordagem do referido veículo, identificando a motorista como sendo a ré Carla Fernanda Fani, conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico. Com ela e no veículo, nada de ilícito foi encontrado. Questionada, a ré Carla informou que possuía entorpecente em sua residência e autorizou o ingresso dos policiais, fornecendo, inclusive, as chaves e o controle do portão do imóvel.

Os policiais, então, entraram na casa e fizeram contato com o marido dela, Raphael Naya Souto, que indicou possuir entorpecente e uma arma de fogo. Foram apreendidos 103 (cento e três) porções de cocaína, pesando 65,71 gramas, 01 (uma) balança de precisão, vários saquinhos ZipLoc vazios, a quantia de R\$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) em espécie, 02 (dois) cadernos com anotações relacionadas ao

tráfico de drogas, 01 (uma) pistola, da marca Taurus, calibre 380, número KJR95621, com um carregador municiado com 16 (dezesseis) munições intactas, marca CBC, do mesmo calibre.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Lembre-se, outrossim, que os policiais afirmaram que a ré Carla autorizou a entrada deles na residência.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

“De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formodo disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara - Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes

públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupro de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi

devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é "Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE". Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal, V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

No mérito, a ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01; as notas de culpas de fl. 10/11; o boletim de ocorrência acostado às fls. 12/15; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 16/17; o laudo de constatação prévia de fl. 18; os laudos periciais de fls. 264/266 e 268/272; o relatório policial de fls. 165/168; os depoimentos das testemunhas; a confissão apresentada pelo réu Raphael na fase extrajudicial; e as indigestas negativas apresentadas pela acusada Carla em ambas as fases da persecução penal.

A acusada Carla, tanto na delegacia, quanto em juízo, relatou que não tinha conhecimento que tinha drogas, balança de precisão, caderno com anotações e arma na residência. Negou que foi abordada saindo da residência pelos policiais militares. Disse que não morava na residência, pois mora com seu pai para cuidar dele e só vai dormir na residência. Negou que informou que tinha drogas no imóvel e que entregou o controle do portão aos policiais militares e não soube dizer a origem do dinheiro apreendido. Em juízo, afirmou que seu esposo Raphael só confessou na delegacia porque o delegado disse que, caso contrário, ambos ficariam presos (fls. 07 e 277/278).

De início, a alegação da ré Carla de que o acusado Raphael foi pressionado para confessar o crime na fase policial, não pode ser acolhida. Na delegacia, ela negou o tráfico de drogas e disse que não sabia que o marido estava praticando o mercancia ilícita. Em juízo, continuou negando, mas acrescentou que o réu Raphael só confessou na delegacia porque a autoridade policial lhe que informou de que, se não assumisse, ambos seriam presos.

A alegação, todavia, não convence. Primeiro porque, na fase policial, a ré Carla nada mencionou sobre isso, trazendo essa informação somente em juízo. Segundo, porque nem mesmo o réu, em seu interrogatório judicial, deu essa versão.

Por sua vez, acusado Raphael, na delegacia, disse que quando os policiais chegaram em sua residência, eles entraram com o controle do portão de sua esposa e perguntaram se havia algo de ilícito dentro do imóvel. Respondeu que tinham droga e arma, sendo o entorpecente destinado ao consumo próprio e a arma para garantir sua segurança, pois tem problemas com outros "caras na rua". Disse que vendia parte da droga para manter o vício. No caderno anotava ajustes relacionados à venda e compra de carros. Por fim, disse que sua esposa não tem nada a ver com o que o faz (fl. 06).

Em juízo, o acusado Raphael, sob o crivo do contraditório, preferiu exercer o direito de permanecer em silêncio (fls. 277/278), desperdiçando importante

oportunidade para apresentar uma versão convincente dos fatos sob as garantias do contraditório judicial. Aliás, o fato de o réu Raphael ter ficado em silêncio, embora não se deva tomar por prova plena e cabal de sua culpa, induz à invencível perplexidade quanto à sua inocência, pois repugna a razão deixe alguém de responder aos termos de uma acusação, máxime se inocente. Com o silêncio, pois, o réu teve atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo a oportunidade de esclarecer equívoco da acusação, lembrando que, na fase policial, o acusado Raphael chegou a confessar a prática do tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo. Lembre-se que o silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, nos termos do artigo 198 do Código de Processo Penal.

A confissão extrajudicial do acusado Raphael encontrou respaldo nos depoimentos das testemunhas Rafael Lyudi Mizugai e Alekssander Xavier Conrado, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, os quais disseram que receberam uma denúncia anônima que uma mulher de nome "Carla", que estava foragida da justiça, que andava em um Toyota/Corolla de cor preta, estaria residindo em novo endereço, sendo pela Rua Santos Puerta Garcia, nº 834. Carla Fernanda Fani já era conhecida nos meios policiais, e com o Mandado de Prisão em mãos intensificou patrulhamento, momento em que avistaram um veículo com as mesmas características saindo da garagem do endereço citado e, após alguns quarteirões, abordaram o veículo, sendo a condutora Carla. Nada de ilícito fora localizado no veículo. Indagada, a acusada Carla informou que havia drogas em sua residência e autorizou a busca no local, inclusive, fornecendo as chaves e o controle do portão do imóvel. Na residência, estava seu marido Raphael Naya Souto, que também admitiu que havia drogas e arma na residência, indicando onde estavam. Foram localizados 103 porções de cocaína, uma balança de precisão, vários ziploc (saquinhos) vazios, o valor de R\$ 526,00 em dinheiro, 02 cadernos contendo anotações do tráfico de drogas, uma arma de fogo com 16 munições intactas. Por fim, disse que as drogas estavam em local de fácil visualização (fls. 02/03, 04/05 e 277/278).

Como se vê, os policiais militares confirmaram que localizaram drogas e arma de fogo na residência dos acusados.

Anoto que o valor do depoimento de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando seus depoimentos não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de condutas definidas como crimes, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Ainda quanto aos policiais militares, é cediço que o valor de seus depoimentos testemunhais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Note-se, ainda, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, logo, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-los, apenas por se tratar de policiais.

Quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se, ainda:

"Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação, ou tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Procedente" (STF - 2a T. - HC n.º 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167)."".

“Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1a Turma – HC n.º 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Por tudo que foi exposto quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há o que se questionar quanto as suas declarações.

Quanto à arma de fogo e munições, o laudo pericial de fls. 268/266 apurou que: “Seus mecanismos encontram-se aptos para a realização de disparo, conforme testes de prova aqui efetuados. (...) Conforme testes experimentais realizados no 16 (dezesesseis) cartuchos íntegros, todos deflagraram normalmente e estavam aptos a realização de disparos”.

No que se refere aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em “cocaína” (exame químico-toxicológico de fls. 264/266).

De outra parte, o entorpecente apreendido, ou seja, 65,71 gramas de cocaína; as circunstâncias da abordagem dos réus (cumprimento de mandado de prisão por tráfico em desfavor da acusada Carla), a forma de acondicionamento da droga (distribuídas em porções prontas para o comércio); apreensão de sacos plásticos “zip lock”, balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e dinheiro; a confissão informal dos réus aos policiais militares; e a confissão apresentada pelo réu Raphael na fase policial, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram apreendidos balança de precisão, sacos “zip lock” vazios e cadernos com anotações do tráfico, juntamente com as drogas, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, estes apetrechos são utilizados para gerenciar, quantificar e embalar as porções que serão vendidas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente tenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, os réus foram denunciados porque tinham em depósito os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

O simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, os acusados não fizeram qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados Raphael Naya Souto e Carla Fernanda Fani tinham em depósito 65,71

(sessenta e cinco gramas e setenta e um centigramas) de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, e possuíam, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, número KJR95621, de uso permitido, acompanhada de 16 (dezesesseis) munições íntegras, marca CBC, calibre 380, de uso permitido, sendo que o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As condutas dos réus encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10.826/03.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, exclua a culpabilidade dos denunciados ou extingam as punibilidades. Neste ponto, embora o acusado Raphael tenha alegado que é usuário de drogas, tal alegação não restou comprovada, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu Raphael fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Tanto é assim que, na fase policial, o réu Raphael afirmou que vendia parte da droga para manter o vício.

Reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas separadamente.

Das penas.

Posse ilegal de munição de uso permitido.

Réu Raphael

O acusado ostenta mau antecedente (fl. 375 - Processo nº 0002227-18.2010.8.26.0032), razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não lhe são favoráveis e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 375/376 - Processo nº 0009223-81.2016.8.26.0077) e aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa. No mais, não há outras agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Torno, pois, definitiva a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Réu Carla

A ré não registra maus antecedentes e as demais circunstâncias do artigo 59 não lhe são desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da multirreincidência (fl. 371 - Processo nº 1503611-83.2019.8.26.0077 e fls. 371/372 - Processo nº 1500509-61.2018.8.26.0603) e aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa. No mais, não há outras agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Torno, pois, definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Tráfico de drogas.

Réu Raphael

O acusado ostenta mau antecedente (fl. 375 - Processo nº 0002227-18.2010.8.26.0032), razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não lhe são favoráveis e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 375/376 - Processo nº 0009223-81.2016.8.26.0077) e aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. No mais, não há outras agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, o que afasta o benefício.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ré Carla

A acusada não ostenta maus antecedentes e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da multirreincidência (fl. 371 - Processo nº 1503611-83.2019.8.26.0077 e fls. 371/372 - Processo nº 1500509-61.2018.8.26.0603) e aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. No mais, não há outras agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a ré, apesar de possuir bons antecedentes, é reincidente específica, o que afasta o benefício.

Torno, pois, definitiva a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Observo que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Quanto ao tráfico de drogas, diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP) em relação ao réu Raphael, as penas de ambos devem ser cumpridas no regime fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, no tocante ao acusado Raphael, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo, diante das penas aplicadas e levando em conta que o réu Raphael é reincidente e ostenta mau antecedente, e a ré Carla é multirreincidente, entendo que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para ambos deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código



Penal.

O acusado Raphael deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Por outro lado, a acusada Carla foi solta mediante liberdade provisória concedida na audiência de custódia e assim permaneceu durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder ao processo em liberdade.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Neste ponto, anoto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que inexistente previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.

Ademais, cabe consignar que a pena de multa é uma modalidade de reprimenda cominada à infração penal, sendo vedada a sua exclusão, sob pena de o pedido de isenção formulado pelo sentenciado se transmutar em supedâneo recursal, o que, em hipótese alguma, se pode admitir.

Descabida, portanto, a pretensão da defesa técnica quanto ao não pagamento da multa imposta ao réu Raphael.

Quanto ao pedido relativo à dispensa das custas processuais, o mesmo não comporta acolhimento, pelos mesmos motivos já expostos acima, lembrando que, recentemente, o Tribunal de Justiça editou ato normativo aos juízes, para que se empenhem na cobrança das custas processuais devidas em processos criminais, nos termos do que determinam as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

1) CONDENAR CARLA FERNANDA FANI ao cumprimento pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-a como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento);

2) CONDENAR RAPHAEL NAYA SOUTO ao cumprimento pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-o como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento);

Apesar de preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena não superior a quatro anos) para ambos, entendo que os requisitos dos incisos II e III do mesmo artigo não se mostram presentes, porque o acusado Raphael ostenta mau antecedente e é reincidente em crime doloso e a ré Carla é multirreincidente. Afora isso, entendo que a substituição não é suficiente para a repressão e prevenção dos delitos, porque admitir traficantes de drogas prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive crianças inocentes, o que, de forma alguma, se pode admitir.

3) CONDENAR CARLA FERNANDA FANI, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-a como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06;

4) CONDENAR RAPHAEL NAYA SOUTO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado Raphael ficou preso cautelarmente desde 08/04/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se

consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detratação penal).

Quanto a este crime (tráfico), deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 0094294-30.2012.8.26.0000, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que as penas fixadas ultrapassam quatro anos, além do que o réu Raphael é reincidente e ostenta mau antecedente e a ré Carla é multirreincidente, o que afasta de vez a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, CP). Ademais, os réus são reincidentes específicos, o que afasta até mesmo a aplicação do § 3º do mesmo artigo e Diploma.

O acusado Raphael deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 90/93), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado Raphael, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos.

Lembrando que o acusado é reincidente específico no tráfico de drogas e ostenta mau antecedente criminal.

Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o réu RAPHAEL na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos

59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A acusada Carla foi solta mediante liberdade provisória concedida na audiência de custódia e assim permaneceu durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder ao processo em liberdade.

A incineração da droga apreendida já foi determinada e realizada (fls. 241), razão pela qual nada há a ser decidido a respeito.

Restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido (fls. 16/17), razão pela qual não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente praticado pelo acusado. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos saquinhos plásticos vazios, balança de precisão e cadernos, diante da natureza dos objetos, entendo não ser caso de perda, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos, independentemente do trânsito em julgado da presente.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos e perdimento do dinheiro apreendido, instruindo-se o ofício com as cópias. No tocante à arma de fogo e munições apreendidas (fls. 16/17), já foi elaborado o laudo pericial e as partes dele já tomaram ciência. Não há notícia de que a munição pertença a terceiro de boa-fé, para fins de notificação quanto ao interesse em sua restituição, além do que a guarda da munição não é imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados no processo (art. 1º, § 1º, Res. 134/11 do CNJ). Portanto, com fundamento no artigo 1º, caput, da Resolução nº. 134/11 do Conselho Nacional de Justiça, c.c. o artigo 3º do Provimento nº 1924/11 do Conselho Superior da Magistratura, determino o encaminhado da munição ao Comando do Exército, para destruição, nos termos do artigo 25 da Lei nº. 10.826/03, independentemente do trânsito em julgado.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA